

1502185-43.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... do indiciado, o qual estava na prática de tráfico de entorpecentes na Rua Imbauva, escadão, local onde tinham prévio conhecimento acontecia o tráfico de entorpecentes. Em poder do indiciado foram encontrados invólucros contendo erva aparentemente maconha e outros com pó aparentemente cocaína, além da quantia de R\$ 11,00. Próximo do local onde aconteceu a prisão está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502185-43.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300470/2021 - 04º D.P. DIADEMA, 21201303 - 04º D.P. DIADEMA, 2291/21/129 - 04º D.P. DIADEMA, 2300470 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Henrique Rosa Araujo da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE ROSA ARAUJO DA SILVA, qualificado às fls. 04 e 09/10 está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 09h30, nas proximidades da Escola Municipal Carolina Maria de Jesus e da Unidade Básica de Saúde - UBS do Inamar, Rua Imbauva, nº 251, Inamar, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 31 embalagens plásticas contendo 20,09g da droga cocaína e 79 papérolas contendo 225,35g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 12/13 e laudo de constatação provisória de fls. 17/19, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.37/40), o réu foi notificado e citado (fls. 70 e 113), e apresentou defesa preliminar as fls. 78/80, através do d. Defensor Público que lhe foi nomeado. Não sendo hipótese de ANPP diante da reincidência do agente, nem de arquivamento, a denúncia foi recebida em 23/03/2022 (fls.81).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente pelas Partes, e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

O d. Promotor de Justiça pretendeu a procedência da ação por provadas autoria e materialidade delitivas, com a fixação da pena base acima do mínimo legal diante da grande quantidade e variedade de drogas, com a agravante da multirreincidência, com o aumento da pena pelo local da venda de drogas ser perto de uma UBS e de uma escola municipal, sem sua redução nem sua substituição nos moldes do art. 44 d CP, fixando-se regime fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade, além da perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição ante a fragilidade da prova. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com a atenuante da confissão informal, afastando-se a causa de aumento pela localização geográfica da biqueira ante ausência de nexo causal, com possibilidade de redução da pena ainda que em patamar inferior, fixando-se regime compatível com a pena e com o tempo de prisão do réu por este processo, facultando o recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 12/13, nos autos de constatação e no definitivo (fls.17/19 e 109/111), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.2/3), procederam a abordagem do indiciado, o qual estava na prática de tráfico de entorpecentes na Rua Imbauva, escadão, local onde tinham prévio conhecimento acontecia o tráfico de entorpecentes. Em poder do indiciado foram encontrados invólucros contendo erva aparentemente maconha e outros com pó aparentemente cocaína, além da quantia de R\$ 11,00. Próximo do local onde aconteceu a prisão está instalada a Escola Municipal Carolina Maria de Jesus e a Unidade Básica de Saúde Inamar.

Sob o crivo do contraditório o policial Flávio Augusto Moreira confirmou que o local é conhecido como venda de drogas. O réu estava de pé com um volume na cintura. Desembarcou para fazer a abordagem e ele correu. Foi abordado mais pra frente e na cintura dele estavam as substâncias entorpecentes e no bolso da calça dele tinha uma quantia em dinheiro e ele confessou informalmente que estava na venda de entorpecentes. Foi a primeira vez que viram o réu no local, que fica ao lado de uma UBS e por uma escola, pois é acesso à elas, passando no meio do tráfico de drogas. Não perdeu o réu de vista durante a perseguição.

Igualmente o policial Amaro Serafim respondeu ao juiz que a equipe estava em patrulhamento em local já conhecido como ponto de venda de drogas. O acusado assim

que os viu, fugiu a pé. Houve um breve acompanhamento e o deteve. Com ele localizou uma sacola com diversos entorpecentes dentro (cocaína, maconha e crack), uma boa quantidade. O réu confessou a venda de drogas e foi a primeira vez que o viu no local, que fica perto de uma escola e de uma UBS. O local é de grande fluxo de pessoas e alunos. Reconhece o réu como sendo a pessoa de quem está falando. Correu atrás dele uns vinte metros e ele foi detido na mesma via, não o tendo perdido de vista. As drogas estavam em uma sacola, na cintura. O réu estava sozinho e só ele correu. O acusado confessou o crime no local dos fatos, em uma breve entrevista. Seu parceiro ficou na viatura e depois ele veio atrás e viu a prisão.

O réu, em solo policial (fl. 4), respondeu que é viciado no uso de substâncias entorpecentes, e para sustentar seu vício, uma vez que está desempregado, resolveu traficar substâncias entorpecentes. Na manhã de hoje, estava pelo local dos fatos, Rua Imbauva, no escadão, quando foi abordado por policiais militares. Em seu poder tinha uma sacola plástica a qual acondicionava as substâncias entorpecentes que traficava. Não sabe dizer para quem trabalha. Cada invólucro com maconha vendia pelo valor de R\$ 10,00 e os invólucros com cocaína, vendia pelo valor de R\$5,00.

O réu inovou em juízo, oportunidade em que negou o crime alegando que não foi trabalhar no dia e pegou duas blusas para vender e levantar um dinheiro para ir comprar drogas. Entrou no beco, tinha um rapaz. Pediu um crack. Não tinha. Ficou esperando que estava chegando, pois iam abastecer a biqueira. Perguntaram se ele não queria varrer o beco para ganhar mais uma pedra de crack. Aceitou. Viu a viatura chegando, soltou a vassoura e andou. O traficante soltou a sacola e fugiu. O policial achou o pacote de droga dentro da lata do lixo, e o levaram preso. O outro rapaz foi pego por outros dois policiais. É usuário de drogas e só foi lá comprar. Queriam que caguetasse o traficante e não fez porque lhe matam depois. Já teve passagem por furto e uso de droga e roubo. Estava em poder de onze reais proveniente da venda de uma de suas blusas.

Diante do exposto tem-se que a negativa de autoria que o réu trouxe em audiência, já que seu relato judicial (fl 04) está em dissonância com a não, que como visto não veio provada por si nem pela Defesa, quer no sentido de se tratar de mero usuário de drogas, quer no sentido de que estava na biqueira varrendo, limpando, quer que além dele houvesse mais um rapaz que teria corrido e largado a sacola com as drogas, pois segundo relatos dos milicianos, só tinha o réu no local e só ele correu.

Em sentido oposto tem-se a confissão informal e a extrajudicial que vieram corroboradas pelos relatos dos policiais e demais provas, inclusive pericial. Logo, essas confissões não são prova única e vieram corroboradas pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária.

Ora, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo que avistaram na biqueira já conhecida, e era ele quem estava em poder da sacola contendo as drogas e o dinheiro proveniente de suas vendas, tanto que o réu confessou o crime, ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, mas as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. Ademais, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Ainda, a condição de usuário de drogas alegada, e não provada pelo réu nem Defesa, não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos

utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem. Veja: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira). E ainda, no presente caso, não há prova de que o réu seja dependente químico ou usuário de drogas.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (110 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido, são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, especialmente pela grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (110 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado. Em segunda fase, presentes circunstâncias agravantes e atenuantes. O réu é plurirreincidente. Sendo assim, compenso a condenação definitiva por roubo proferida pelo juiz da 9ª Vara da Barra Funda (fl. 24) com a atenuante da confissão, por ter considerado essa prova produzida extrajudicialmente e confirmada em juízo pelos policiais, e por questão de justiça, já que dela me vali para também embasar a condenação, ora será considerada a beneficiar o réu. Mas considerando as três condenações definitivas por furto, cujos feitos tramitaram pela 2ª Vara Criminal de Diadem (fl. 25/26), 1ª e 4ª Varas Criminais de Santos (fls. 27 e 28, respectivamente), agravo a pena em ¼, optando por esse percentual diante do princípio da proporcionalidade, totalizando 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão mais 728 dias-multa.

Em terceira fase, tem-se a causa de aumento de pena do tráfico ter ocorrido próximo a uma escola e a um posto de saúde (art. 40, III, da Lei especial) vizinhos, e a aumentar a pena em 1/6, totalizando 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão mais 849 dias-multa. Ausente causa de redução de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, e ainda que não específico, o que a lei não exige, e por indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal. Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário). Ademais: Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei

8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime. (TJAP) RT 772/617. Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a plurirreincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado por agente multirreincidente, além da excessiva quantidade de droga, o que não constitui bis in idem (a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional), que deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga, e por isso o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por plurirreincidente, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra FERNANDO HENRIQUE ROSA ARAUJO DA SILVA, qualificado às fls. 04 e 09/10 como incurso no artigo 33, caput, c.c.

artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 09h30, nas proximidades da Escola Mune o faço para condená-lo à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora, nos termos da Lei estadual nº 11.608 de 2003.

Decreto a perda de numerário apreendido (fl. 12/13), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

P.I.C.

Diadema, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA